

1500767-65.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO ROBERTO ALVES MACHADO

Data da Audiência:

10/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500767-65.2021.8.26.0571 - Controle 2021/000813

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO ROBERTO ALVES MACHADO

Data da Audiência:

10/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Flávio Roberto Alves Machado. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Kadu Ferreira dos Santos e Ricardo de Souza Almeida Ramos arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 02 de junho de 2021, por volta das 16h10min, na Rua Antônia Ginês de Paula, próximo ao nº 20, Vila Arruda, nesta cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito, 05 (cinco) porções de "cocaína", com peso líquido de 0,48g (quarenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar. O réu foi notificado por edital (fls. 137/138) e apresentou defesa prévia (fls. 143/144). A denúncia foi recebida em 30/11/2021 (fls. 145) e o acusado foi citado por edital, não compareceu em juízo e não constituiu advogado, motivo pelo qual o processo e o prazo prescricional foram suspensos com fundamento no artigo 366 do CPP (fls. 167/168). Após, o réu foi pessoalmente citado (fls. 201). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação (fls. 15/18) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 70/72). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse que estava com os pinos de "cocaína" que havia pegado em um "matinho", local em que guarda sua droga. Contou que tinha recebido a importância de R\$ 70,00 de um trabalho feito no dia anterior ao dos fatos (fls. 04). Interrogado em Juízo, o réu afirmou que a droga era sua, estava guardada no local e era destinada ao seu próprio consumo. Declarou que guardava a droga no local pois já tivera outros problemas com entorpecentes. Enfim, negou o tráfico. Ocorre que a prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhando de rotina no bairro acima mencionado, instante em que foram parados por um transeunte que os informou que "Bebê" estaria na Rua Evilásio Massaine Pires, nas proximidades da "Apae", vendendo drogas. O informante, ainda, mencionou que o acusado guardava as porções na rua lateral da "Apae", nas proximidades da cerca. Em razão disso, os militares resolveram averiguar. Já próximos do local, ao passarem pela esquina, os policiais presenciaram o denunciado exatamente no local onde estariam escondidas as porções, com a mão para dentro do terreno. Ao perceber a aproximação da viatura, FLÁVIO tentou se evadir de bicicleta e lançou os "pinos" de cocaína no chão, porém, acabou sendo abordado e as porções recuperadas. Além das porções de cocaína, foram apreendidos com o acusado um aparelho celular e a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), valores, obviamente, provenientes das vendas anteriores à abordagem. Indagado, o denunciado confessou informalmente aos militares que traficava no local. Pois bem. Agora, a testemunha Kadu - policial militar - disse que a guarnição recebeu informação que dizia que "Bebê", alcunha do réu, estava traficando pelo local. Foi, inclusive, apontado o local onde as drogas se encontravam. Lá chegando, depararam-se com o réu revolvendo um terreno. De imediato, o réu subiu sobre a sua bicicleta e tentou se evadir. A corrente da bicicleta soltou-se e o réu parou. Ele tentou se desvencilhar dos entorpecentes que trazia nas mãos, mas não conseguiu. O réu trazia consigo, também, quantia em dinheiro. O policial Ricardo fez coro às palavras do seu colega. Pontou que, informalmente, o réu admitiu o tráfico. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 28/32). Na segunda fase a pena deverá ser agravada, pois o crime foi praticado durante período de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19. Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O regime prisional poderá ser o inicialmente aberto e nada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 c. c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. I- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta

quantidade entorpecentes e como o réu não foi preso mantendo contato com pessoas, mas apenas – de acordo com os depoimentos – na posse de pequena quantidade de entorpecente, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. Aliás, o próprio réu esclareceu que se trata de usuário e que o entorpecente apreendido era para seu uso. Disse que pegou o entorpecente no terreno, que havia sido deixado pela pessoa de quem comprou, afirmando que se assustou quando a polícia passou e que, realmente, tentou fugir e dispensou os pinos. A acusação se baseia tão somente em denúncia de pessoa que sequer quis se identificar, no sentido de que o réu traficava. No entanto, o que pesa em desfavor do acusado é tão somente essa suposta denúncia. O réu foi apreendido com diminuta quantidade de entorpecente e no local não foram encontradas mais drogas ou apetrechos para o tráfico. Ainda, ele não foi visto em contato com nenhuma pessoa e em situação que indicasse a traficância. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presume que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de as substâncias estarem embaladas individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal. De fato, o caso envolve diminuta quantidade de entorpecente, indicando se tratar de hipótese de uso. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre

organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse

legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no

patamar mínimo legal; b) Na segunda fase de dosimetria da pena deverá ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, caso a suposta confissão informal seja ela valorada pela sentença condenatória; c) seja afastada a agravante pleiteada na denúncia, visto que o estado de pandemia em nada contribuiu ou influenciou para a prática do crime; d) seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixado regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos, ante a primariedade do réu e em conformidade com os arts. 33, 44 e 59 do Código Penal; e) a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica, visto que não há mais razões para manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o encerramento da instrução criminal. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. FLÁVIO ROBERTO ALVES MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 02 de junho de 2021, em período de anormalidade - Pandemia, por volta das 16 h e 10 min, na Rua Antônio Ginês de Paula, próximo ao n. 20, Vila Arruda, nesta Cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinco porções de "cocaína", com peso de 0,48 gramas. O Réu foi notificado, fls. 137/138, e apresentou defesa preliminar, fls. 143/144. A denúncia foi recebida, fls. 145, e o Réu, citado por edital, fls. 150/151, não compareceu em Juízo e não constituiu Defensor, assim o feito foi suspenso com fundamento no art. 366, CPP; na oportunidade foi decreta da prisão preventiva, fls. 167/168. O mandado de prisão foi cumprido, fls. 177/191, na sequência o Réu foi citado pessoalmente, fls. 201. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a desclassificação. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 07/09, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 10/11, bem como no Laudo de Constatação, fls. 15/18 e de Exame químico-toxicológico n. 180.717/2021, fls. 70/72, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Às fls. 153/155 foi juntado o Laudo Pericial de Exame em Peça - Celular, n. 381.008/2021, no qual consignou: "II - DA PEÇA E DO EXAME Em embalagem com lacre nº 00004830 encontrava-se 01 (um) celular da marca Motorola, remetido ao Núcleo de Perícias Criminalísticas de Sorocaba para extração dos dados, a fim de responder ao requerido no objetivo da perícia. O resultado do exame segue em Relatório de Análise nº 401.724/2021, recebido no dia 13/01/2022, juntamente com a peça de exame com lacre SPTC nº 0366120, acompanhando o presente laudo.". Às fls. 156/161 foi juntado o Relatório de Análise n. 401.724/2021 no qual consignou: "6. CONSIDERAÇÕES FINAIS Tendo em vista a natureza dos fatos investigados, solicita-se respeitosamente à Vossa Excelência que, caso entenda necessário, reencaminhe requisição de exame complementar acompanhada de padrão para desbloqueio, para novas tentativas de extração de dados". Kadu Ferreira dos Santos e Ricardo de Souza Almeida Ramos, policiais militares, disseram que vinham recebendo denúncias de tráfico de entorpecentes pelo Réu e, no dia dos fatos, aportou nova denúncia, segundo a qual o Réu estava comercializando entorpecentes e os armazenava em um muro ao lado de APAE; foram ao local e viram o Acusado nesse ponto, com a mão na cerca da APAE, ele não viu os policiais, mas, ao receber ordem de parada, fugiu, todavia a correia da bicicleta escapou e ele arremessou os pinos; feita a abordagem, com ele houve apreensão de dinheiro e de celular; no chão estavam os pinos de "cocaína", um dos quais estava aberto. O Réu confessou o tráfico de entorpecentes. Flávio Roberto Alves Machado, Réu, ao ser interrogado, disse que as drogas eram suas, mas destinadas ao uso pessoal; guardava-as naquele local porque não as queria na casa, isso para evitar problemas. Não admitiu o comércio ilícito perante os policiais. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a desclassificação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, o qual estava abaixado em um terreno e com as mãos na cerca, e, em virtude dessa conduta e das denúncias, fizeram a

abordagem, quando o Réu fugiu e depois arremessou as porções de “cocaína”. Com o Acusado houve apreensão de dinheiro e de celular. O testemunho dos policiais é seguro e coerente, todavia o Réu confessou que a droga apreendida lhe pertencia, porém aduziu que a tinha adquirido para seu uso. A quantia apreendida é pequena e compatível com a destinação pessoal e não foi presenciado pelos policiais qualquer ato de alienação. Não se olvida a suposta confissão informal e as denúncias pretéritas, mas estas são insuficientes para a condenação do Réu por tráfico de entorpecentes. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar, FLÁVIO ROBERTO ALVES MACHADO, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Defiro a liberação do dinheiro e do celular. Sem condenação nas custas. O Réu estava preso em virtude de ter mudado de endereço sem comunicar o Juízo, e, neste momento, encerrada a instrução criminal e à vista da pena aplicada, poderá interpor eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 10 de maio de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA